

<제09장 무효등 확인소송.제07절 청구의 병합과 소의 변경>

[예상][9.07-2]무효확인소송에서 취소소송으로의 변경 시 제소기간 준수의 기준 시점

《【문제9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국제 체납을 이유로 `압류처분`을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음2) 乙이 `무효확인소송`을 `취소소송`으로 변경하고자 할 때, 소 변경의 요건 중 하나인 `제소기간의 준수 여부`를 판단하는 기준 시점에 대하여 행정소송법 규정을 근거로 설명하라.》

<문제9.7의 물음2> 무효확인소송에서 취소소송으로의 변경 시 제소기간 준수의 기준 시점

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 영업정지 처분에 대한 무효확인소송을 제기한 후 해당 처분이 취소사유에 해당함을 이유로 취소소송으로 소를 변경하려 하나, 변경 시점에는 취소소송의 제소기간이 도과한 상황이다. 쟁점으로 <소의 종류 변경 시 제소기간 준수 여부를 판단하는 기준 시점이 최초 소 제기 시인지 변경 신청 시인지 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정소송법상 소의 변경 규정에 따른 제소기간 준수 여부의 판단 기준 시점을 설명한다.

II. 소의 종류의 변경의 의의 및 요건

1. 의의

- 소의 종류의 변경이란 원고가 청구의 기초에 변경이 없는 한 소송의 계속 중에 소의 종류를 항고소송 상호 간 또는 항고소송과 당사자소송 간에 변경하는 것을 말한다. 乙의 경우 무효확인소송이라는 항고소송을 취소소송이라는 다른 항고소송으로 변경하는 경우에 해당한다.

2. 일반적 요건

(1) 소의 계속과 사실심 변론종결 전

- 구소인 무효확인소송이 법원에 적법하게 계속되어 있어야 하며, 소의 변경 신청은 항소심을 포함한 사실심의 변론종결 전까지 이루어져야 한다.

(2) 청구의 기초의 동일성

- 구소와 신소의 청구 원인이 되는 기초적 사실관계가 동일해야 한다. 영업정지 처분이라는 동일한 행정작용을 대상으로 하므로 이 요건은 충족된다.

(3) 법원의 허가 및 피고의 의견 청취

- 법원은 소의 변경이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 이를 허가하며, 이때 피고의 의견을 들어야 한다.

III. 제소기간의 준수 여부와 기준 시점

1. 행정소송법의 규정 근거

- "행정소송법 제21조 제4항"은 소의 종류의 변경이 있는 경우 "제14조 제4항" 및 "제5항"의 규정을 준용하도록 하고 있다. 준용되는 "제14조 제4항"은 피고경정 시의 제소기간에 관한 규정으로, 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 때에는 처음에 소를 제기한 때에 소가 제기된 것으로 본다고 명시하고 있다.

2. 소급효의 인정

- 위 규정에 따라 乙이 무효확인소송을 취소소송으로 변경하는 신청을 하고 법원이 이를 허가한 경우, 신소인 취소소송은 소를 변경한 시점이 아니라 처음에 무효확인소송을 제기한 시점에 제기된 것으로 간주된다. 이를 소의 변경에 따른 소급효라고 한다.

3. 무효확인소송 제기 당시의 제소기간 준수 필요성

- 다만, 이러한 소급효가 인정되기 위해서는 구소인 무효확인소송 자체가 취소소송의 제소기간(처분이 있음을 안 날로부터 90일 등) 내에 제기되었어야 한다. 만약 처음부터 취소소송의 제소기간을 도과하여 무효확인소송을 제기했다가 나중에 취소소송으로 변경하는 경우에는 소급효를 인정하더라도 신소인 취소소송은 제소기간 도과로 부적법하게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 소 변경 신청 기한

- 사안에서 乙은 소송 심리 중에 소를 변경하고자 하므로 사실심 변론종결 전이라는 시간적 요건을 갖추었다. 乙이 소 변경을 신청하면 법원은 청구의 기초가 동일한지를 판단하여 허가 여부를 결정하게 된다.

2. 제소기간 준수 여부의 판단

- 乙이 소를 변경하려는 현재 시점은 비록 취소소송의 제소기간이 지났으나, "행정소송법 제21조 제4항"에 의해 소급효가 인정된다. 따라서 乙이 처음에 무효확인소송을 접수했을 당시가 영업정지 처분에 대한 취소소송 제소기간 내였다면, 현재 변경된 취소소송은 적법하게 제소기간을 준수 것으로 인정된다.

V. 결론

- 무효확인소송을 취소소송으로 변경하는 경우, 신소의 제소기간 준수 여부를 판단하는 기준 시점은 "행정소송법 제21조 제4항" 및 "제14조 제4항"에 의거하여 구소인 무효확인소송을 처음에 제기한 때이다. 乙이 무효확인소송을 취소소송의 제소기간 내에 제기했다면, 소 변경 시점에 이미 제소기간이 도과했더라도 소급효에 의해 신소인 취소소송은 적법하게 유지될 수 있다. 이러한 법리는 하자의 정도를 오인하여 소송의 종류를 잘못 선택한 원고에게 소급효를 부여함으로써 제소기간의 도과로 인한 불이익을 방지하고 실효적인 권리구제를 도모하는 데 그 취지가 있다.